

1500203-18.2022.8.26.0453

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MOEMA MOREIRA PONCE LACERDA

Comarca: Pirajuí

Foro: Foro de Pirajuí

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 16/11/2022

... transportadas pelo réu tinham por destino o tráfico, e não o consumo próprio. Ou seja, o réu, na data dos fatos, transportava drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Vale ressaltar que restou caracterizado o tráfico entre Estados da Federação, com previsão no art. 40, V, da Lei 11.343/06, tendo em vista que a origem do réu era Foz do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pirajuí

Foro de Pirajuí

1ª Vara

Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 43, Pirajuí - SP - cep 16600-000

1500203-18.2022.8.26.0453 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500203-18.2022.8.26.0453

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELLINGTON FERREIRA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MOEMA MOREIRA PONCE LACERDA

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por seu representante que oficia perante este Juízo, aforou a presente AÇÃO PENAL PÚBLICA, na qual denuncia WELLINGTON FERREIRA como incurso no artigo 33, caput, c.c artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06.

O réu foi preso em flagrante (fls. 01), sendo convertida em prisão preventiva (fls. 42/44).

Narra a denúncia (fls. 70/74) que no dia 31 de março de 2022, por volta de 14 horas, na Rodovia SP-333, na altura do Km 232, no município de Pongai e comarca de Pirajuí, WELLINGTON FERREIRA, qualificado às fls. 04, transportava, no veículo I/Chevrolet Sonic LTZ NB AT, placas OMB1J71, ano 2012, cor vermelho, para fins de venda ou entrega à terceiros, aproximadamente 207,71kg de Cannabis sativa L, droga vulgarmente conhecida como maconha, dividida em 260 (duzentos e sessenta) paralelepípedos (tijolos), conforme auto de exibição e apreensão de fls. 11/12, laudo de constatação provisória de fls. 29/34 e laudo definitivo de fls. 60/62, substância essa que causa dependência física e psíquica, sem autorização legal ou regulamentar.

De acordo com a denúncia (fls. 70/74): "No dia dos fatos, o denunciado partiu da cidade de Foz do Iguaçu, no Estado do Paraná, tendo sido abordado no município de

Pongai Estado de São Paulo, transportando, para fins de tráfico, expressiva quantidade de maconha no interior do veículo que conduzia. Ao que se apurou, policiais militares rodoviários realizavam patrulhamento de rotina pela Rodovia SP-333, quando avistaram o veículo GM/Sonic, cor vermelha, placas OMB1J71 e lhe deram ordem de parada, tendo sido abordado cerca de 05 (cinco) quilômetros à frente, uma vez que tentou se evadir do local. Durante a abordagem, foram encontrados, no interior do porta-malas do veículo, 260 (duzentos e sessenta) tijolos de maconha com peso bruto total de 207,71kg (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 11/12, laudo de constatação provisória de fls. 29/34 e laudo definitivo de fls. 60/62). O denunciado confessou o crime, relatando que partiu da cidade de Patos de Minas, no estado de Minas Gerais, com destino à Foz do Iguaçu/PR, local onde seu veículo foi abastecido com o entorpecente. No dia dos fatos saiu para o transporte da droga, cujo itinerário seria a todo momento passado via aplicativo "Whatsapp" por "batedores" (fls. 04). Considerando a expressiva quantidade da droga apreendida, a forma de acondicionamento (tabletes prensados - tijolo sem balagem típica de comercialização), bem como as circunstâncias da apreensão, foi o denunciado preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia."

O réu foi citado (fls. 112), apresentando defesa prévia (fls. 135/138).

A denúncia foi recebida aos 30 de junho de 2022. A absolvição sumária foi afastada, designando audiência de instrução e julgamento (fls. 147/149).

Em audiência de instrução e julgamento, foi ouvido o informante, duas testemunhas, bem como interrogado o acusado.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais.

O Ministério Público pugnou pela procedência da ação, sob o fundamento de que restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, estando presentes todos os elementos necessários para a caracterização das condutas descritas na denúncia. Por fim, requereu a juntada de certidão de pé das condenações dos réus, para verificar se ele é duplamente reincidente. Após, requer vistas novamente ao Parquet para eventual complementação.

Foi deferida a junta da certidão de objeto de pé solicitada.

Por sua vez, a defesa, em memoriais, postulou pelo reconhecimento das atenuantes previstas no artigo 65, inciso III, alíneas d e e.

Enfim, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A defesa alega nulidade do inquérito policial por ausência de assinatura do réu em seus documentos, inclusive na nota de culpa (fls.5). Contudo, tal alegação não merece prosperar.

De início, registro que os autos do inquérito policial são eletrônicos e, por isso, assinados digitalmente. Tais autos são remetidos ao Poder Judiciário neste mesmo formato (digital), razão pela qual não existem assinaturas físicas nos documentos. Não obstante, os documentos são impressos na delegacia de polícia, assinados fisicamente e arquivados na delegacia de polícia, permanecendo à disposição das partes, razão pela qual mostra-se absolutamente descabida a pretensão defensiva de anulação do feito por tal motivo.

Ademais, conforme jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, ainda que não tivesse sido juntada a nota de culpa, não caberia falar em nulidade. No presente caso, a nota de culpa foi juntada (fls. 05), apenas não contando com a assinatura física do acusado.

Isso porque a defesa não experimentaria qualquer prejuízo com a ausência de nota de culpa nos autos do inquérito policial digital, afigurando-se manifestamente descabido, a esta altura, pretender a anulação do processo pela razão mencionada. Nessa seara, a não demonstração efetiva da existência de prejuízo também inviabiliza, por si só, a anulação pretendida, em face do consagrado princípio "pas de nullité sans grief", nos termos dos seguintes artigos do Código de Processo Penal:

"Art. 565. Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse".

"Art. 566. Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa."

E, sobretudo, a regra do artigo 563 do Código de Processo Penal: "Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa".

Aliás, cabe juntar aos autos acórdão de caso muito semelhante ao presente, em que foi afastada a tese preliminar da defesa:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - Sentença condenatória - Preliminar de nulidade por supostos vícios na fase policial - Não configuração - Os autos do inquérito policial são eletrônicos e por isso assinados digitalmente, ao passo que, no distrito policial, os documentos são impressos e juntados em autos físicos, os quais permanecem à disposição das partes - Inteligência do Item 4 do Comunicado CG nº 2167/2017 - A ausência de nota de culpa nos autos do inquérito policial não acarretou qualquer prejuízo à defesa, incorrendo, portanto, o princípio pas de nullité sans grief - Preliminar de nulidade sobre suposta discrepância entre o entorpecente indicado no auto de apreensão e o apontado no laudo químico-toxicológico - Impertinência - Apontamento inicial da substância Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, constatando-se, posteriormente, tratar-se de MDMB-4en-PINACA, vulgarmente conhecida como k7 ou, ainda, maconha sintética, tratando-se, portanto, de substâncias análogas, o que justifica o apontamento inicial - Absolvição - Descabimento - Materialidade e autoria comprovadas - Conduta que se amolda ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 - Prova cabal a demonstrar que o recorrente recebeu as drogas apreendidas para fins de tráfico - Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais possuem o condão de embasar o decreto condenatório - Causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06 devidamente configurada - Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico - PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1500022-25.2021.8.26.0300; Relator (a): Fátima Gomes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jardinópolis - 2ª Vara; Data do Julgamento: 03/04/2022; Data de Registro: 03/04/2022)

Ainda, a defesa alega que não houve a citação pessoal do acusado, conforme determinação do Código de Processo Penal (artigo 396) e Lei de Drogas (artigo 55 da Lei nº 11.343/2006). Contudo, a mera análise dos autos afasta a tese defensiva preliminar. Conforme o Mandado de Citação digitalizado aos autos (fls. 111), há a assinatura de próprio punho do acusado. E, em reforço, o Sr. Oficial de Justiça certificou nos autos que, em cumprimento ao referido Mandado, foi realizada a notificação do réu, com a informação de que este recebeu a contrafé e exarou sua assinatura (fls. 112).

Afastadas as alegações de nulidade, o feito encontra-se em ordem.

Presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições da ação e os pressupostos processuais. Portanto, pertinente a análise do mérito da causa.

Cuida-se de ação penal pública, na qual a acusação imputa a prática de fato tipificado no artigo 33, caput, c.c art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/06.

Passo a análise da prova oral produzida.

JULIANO SOARES SILVA, em solo policial narrou que: "QUE NESTA DATA POR VOLTA DAS 14:00 HORAS, NA RODOVIA SP 333, KM 232, MUNICÍPIO DE PONGAÍ, QUANDO AVISTARAM O VEÍCULO GM SONIC, COR VERMELHA E AO DAREM SINAL DE PARADA O CONDUTOR DO VEÍCULO TENTOU EVADIR-SE POR CERCA DE 05 QUILOMETROS ATÉ SER ABORDADO. INFORMA QUE NO PORTA MALAS DO VEÍCULO HAVIA CERCA 260 TIJOLOS DE MACONHA. INFORMA QUE O AUTOR WELLINGTON ALEGOU QUE SAIU DE PATOS DE MINAS-MG NA SEGUNDA FEIRA E VIAJOU ATÉ FOZ DO IGUAÇU-PR ONDE CARREGARAM O VEÍCULO COM OS ENTORPECENTES E IRIA ENTREGA-LOS EM UMA CIDADE A SER DEFINIDA PELOS BATEDORES E TAMBÉM NÃO SABE QUANTO IRIA RECEBER PELA VIAGEM. INFORMA QUE DIANTE DOS FATOS DEU VOZ DE PRISÃO AO AUTOR, APRESENTANDO-O NESTA UNIDADE POLICIAL." - fls. 02.

Em juízo, JULIANO SOARES SILVA informou que foi dada sinal de parada obrigatória ao veículo que o réu estava conduzindo, todavia o réu desobedeceu por cerca de 5km. Ao parar em uma porteira, o réu foi abordado e encontrada a droga. Era aproximadamente

170kg de maconha. O réu afirmou que saiu de Pato de Minas, foi até Foz do Iguaçu, e o destino ele não sabia porque aguardava informação dos batedores que estavam na sua frente. Também não sabia qual o valor iria receber.

WELLINGTON WAIKESSEL AMUD, em solo policial, narrou que “NESTA DATA POR VOLTA DAS 14:00 HORAS, NA RODOVIA SP 333, KM 232, MUNICÍPIO DE PONGAÍ, QUANDO AVISTARAM O VEÍCULO GM SONIC, COR VERMELHA E AO DAREM SINAL DE PARADA O CONDUTOR DO VEÍCULO TENTOU EVADIR-SE POR CERCA DE 05 QUILOMETROS ATÉ SER ABORDADO. INFORMA QUE NO PORTA MALAS DO VEÍCULO HAVIA CERCA DE 260 TIJOLOS DE MACONHA. IMFORMA QUE O AUTOR WELLINGTON ALEGOU QUE SAIU DE PATOS DE MINAS-MG NA SEGUNDA FEIRA E VIAJOU ATÉ FOZ DO IGUAÇU-PR ONDE CARREGARAM O VEÍCULO COM OS ENTORPECENTES QUE IRIA ENTREGA-LOS EM UMA CIDADE A SER DEFINIDA PELOS BATEDORES E TAMBÉM NÃO SABE QUANTO IRIA RECEBER PELA VIAGEM. INFORMA QUE DIANTE DOS FATOS O AUTOR RECEBEU VOZ PRISÃO SENDO APRESENTANDO NESTA UNIDADE POLICIAL.” - fls. 03.

Em Juízo, WELLINGTON WAIKESSEL AMUD informou que estavam de serviço e foi dada a ordem de parada ao réu, mas ele se evadiu. Ao chegar em uma porteira fechada de um imóvel rural, o réu parou o carro e foi abordado. Foi encontrada a droga (maconha), pelo o que se recorda, no porta-malas do carro. O réu pegou a droga próximo a Foz do Iguaçu para Minas. O réu disse que ainda não sabia para qual cidade iria, estava esperando uma resposta dos batedores. O réu permaneceu dentro do carro, desceu ao ser pedido, e não esboçou reação. O réu empreendeu fuga por 4-5km.

Em solo policial, o réu declarou que: “ALEGA QUE RESIDE EM PATOS DE MINAS-MG E SAIU NA SEGUNDA-FEIRA DE VIAGEM COM DESTINO A FOZ DO IGUAÇU-PR ONDE FICOU EM UM HOTEL E O PESSOAL, QUE NÃO CONHECE, CARREGOU O VEÍCULO COM ENTORPECENTES. ALEGA QUE NESTA DATA SAIU DE VIAGEM E A TODO MOMENTO RECEBIA MENSAGENS DE VOZ DETERMINADO PARA ONDE IR. ALEGA QUE TINHA BATEDORES QUE LHE PASSAVA AS INSTRUÇÕES. ALEGA QUE NÃO SABE O DESTINO DA DROGA, POIS A TODO MOMENTO RECEBIA INSTRUÇÕES VIA APLICATIVO WHATSAPP, BEM COMO NÃO SABE QUANTO RECEBERIA PELA VIAGEM. ALEGA QUE ESTA RESPONDENDO DOIS PROCESSOS POR TRAFICO NO ESTADO DE MINAS GERAIS.” - fls. 04.

Em juízo, o acusado narrou que fez o transporte da droga. Estava com depressão e, por isso, começou a ingerir bebida alcoólica. Após, iniciou o uso do crack. Por não ter dinheiro para comprar mais, ficou devendo aos traficantes. Por isso, o colocaram para transportar a droga. Havia outras pessoas e foram levados até Foz do Iguaçu. A ordem é que levasse até sua cidade esta droga. Estava cumprindo a pena por tráfico em regime domiciliar. Pagou a outra pena de 2009 a 2014. Era o dia que tinha que assinar seu regime domiciliar, não pensava em ganhar dinheiro. Quer pagar sua pena logo para voltar sua vida, não usará mais drogas porque está pagando caro. Suas outras condenações é porque é usuário e transportava e tinha em depósito, nunca vendeu. Optou por ser preso, ao invés de ser morto. Não tem intenção nenhuma de fazer delação premiada, só quer ser condenado rápido. Perdeu a data de assinar sua domiciliar, mas não tinha outra opção, mesmo sabendo ser preso.

Eis a prova produzida.

Encerrada a exposição da prova oral convém salientar que a ação penal é procedente, a fim de condenar WELLINGTON FERREIRA, sob o fundamento de que restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade delitiva quanto ao delito descrito na denúncia.

A existência material do crime de tráfico ficou comprovada, consoante se depreende do auto de prisão em flagrante (fls. 01), do auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), do laudo pericial de constatação prévia (fls. 29/34), boletim de ocorrência (fls. 06/08), bem como pela prova oral colhida no decorrer da instrução criminal. Quanto à autoria, a condenação do réu Wellington Ferreira é medida consequencial da prova existente nos autos.

Em relação aos policiais, não há nos autos nenhum elemento que identifique a intenção deles em prejudicar o réu. Pelo contrário, o relato dos policiais guarda precisão com as demais provas colhidas.

Destaco que a palavra dos policiais na fase inquisitiva, não está sujeita às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, por cuidar o inquérito policial de procedimento meramente informativo. Todavia, os policiais foram ouvidos em juízo e, nesta oportunidade, cuidou-se de observar todas as garantias inerentes ao devido processo legal.

Com efeito, verifica-se dos autos que, quando da oitiva, respeitado o contraditório, pois presente o réu e seu defensor, tiveram estas plenas condições de se manifestar, fosse mediante reperguntas, pedidos de esclarecimentos ou impugnações que entendessem relevantes.

Ademais, seria um contrassenso o Estado conceder aos agentes de segurança pública crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado juiz, dão conta das suas atividades.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. 1. O exame da tese de fragilidade da prova para sustentar a condenação, por demandar, inevitavelmente, profundo reexame do material cognitivo produzido nos autos, não se coaduna com a via estreita do writ. Precedentes. 2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. 3. Ordem denegada (STJ, 5ª Turma, HC nº 115516/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Data do julgamento: 03/02/2009, Data da publicação: 09/03/2009.).

APELAÇÃO CRIMINAL - Art. 16, "caput", da Lei 10.826/03 - Recurso da defesa - Absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência de provas - Improcedência - Os firmes e coesos depoimentos dos policiais militares reputam-se suficientes para a comprovação dos fatos - Atipicidade - Inadmissibilidade - Delito de perigo abstrato que não requer, para sua caracterização, a demonstração de qualquer situação de risco no caso concreto - Precedentes do C. STJ - Potencialidade lesiva das munições constatada por laudo pericial - Necessária a desclassificação para crime de posse de arma/munição de uso permitido (art. 12, "caput", da Lei 10.826/03) - Aplicação da 'novatio legis in melius' - Superveniência da portaria 1.222 de 12/08/2019 e do decreto 9.847/2019, que reclassificaram as armas e munições de uso permitido e restrito ou proibido - Penas redimensionadas - Recurso defensivo parcialmente provido. (TJSP, 8ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal nº 0001753-88.2018.8.26.0542, Rel. Des. Sérgio Ribas, Data do julgamento: 21/12/2020, Data da publicação 21/12/2020)

Os fatos apresentados nos autos permitem concluir a prática do tráfico de drogas: a quantidade de drogas apreendida é muito superior ao necessário para o consumo de uma só pessoa (mais de 200kg); a forma em que estavam condicionadas (tabletes) e a apreensão de R\$598,00 e 02 aparelhos celulares.

A propósito, está disposto no § 2º, do artigo 28, da Lei nº 11.343/2006: § 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Estabelecida tal premissa, saliento que, em seu interrogatório, o réu confessou que sabia que estava transportando entorpecentes, sendo que pegou o carro em Foz do Iguaçu, carregado de entorpecentes e recebia instruções por meio de aplicativo de troca de mensagens (WhatsApp).

Outrossim, é importante atentar-se para o fato de que as testemunhas, policiais militares rodoviários que atenderam a ocorrência, narraram com riqueza de detalhes como se deu a apreensão da droga.

Portanto, o simples fato do réu transportar as drogas caracteriza a prática pelo réu do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Em suma, há indícios em abundância (quantidade de drogas apreendidas, forma de acondicionamento dos entorpecentes, declarações em solo policial do acusado) que, em conjunto, permitem concluir com segurança que as drogas transportadas pelo réu tinham por destino o tráfico, e não o consumo próprio. Ou seja, o réu, na data dos fatos, transportava drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Vale ressaltar que restou caracterizado o tráfico entre Estados da Federação, com

previsão no art. 40, V, da Lei 11.343/06, tendo em vista que a origem do réu era Foz do Iguaçu/PR, conforme alegado pelo próprio réu em seu interrogatório. Constatada a tipicidade, ilicitude e culpabilidade do fato, passo a dosar a pena do crime, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Artigo 33, caput, c.c artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06.

Primeira etapa.

Análise individualmente cada uma das circunstâncias judiciais:

A) Culpabilidade: O dolo no caso permaneceu dentro do ínsito ao tipo penal, não cabendo o agravamento da pena.

B) Antecedentes: Não há antecedentes, consoantes certidões de fls. 38 e 39/40.

C) Conduta social: Não há informações referentes à conduta social do réu, não cabendo o agravamento da pena.

D) Personalidade: Não há informações referentes à personalidade do réu, não cabendo o agravamento da pena.

E) Motivos do crime: Não há informações referentes aos motivos do crime, não cabendo o agravamento da pena.

F) Circunstâncias do crime: As circunstâncias do crime não apresentam elementos que impliquem no aumento da pena.

G) Consequências do crime: Ausentes informações quanto às consequências do crime, não cabendo o agravamento da pena.

H) Comportamento da vítima: O crime não possui vítima determinada.

I) Natureza e quantidade da droga: Sem agravamento na primeira fase, porque as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena, sob pena de bis in idem (Nesse sentido: STF. Plenário. HC 112776/MS e HC 109193/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, julgados em 19/12/2013 e STF. 2ª Turma. RHC 122684/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 16/9/2014).

Da análise das circunstâncias judiciais, fixo, na primeira fase, a pena em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda etapa.

Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes.

O réu confessou os fatos (artigo 65, inciso III, d). Todavia, deixo de reduzir a pena por já se encontrar em seu mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Ademais, não faz jus ao réu à atenuante prevista no artigo 65, inciso III, e, porquanto a situação de coação por ele vivenciada não foi demonstrada nos autos, bem como tal atenuante visa reduzir a pena daquele que cometeu o delito em multidão. Não é o caso dos autos.

Diante das circunstâncias agravante e atenuante, mantenho a pena em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Terceira etapa

Quanto à causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 necessárias algumas considerações.

O artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, prevê aplicação do redutor somente no caso de preenchimento cumulativo dos requisitos elencados, quais sejam, agente primário, bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e não integrar organização criminosa. É uma benesse cuja aplicação deve se dar somente nos casos em que, de fato, os requisitos estejam preenchidos sob pena de gerar impunidade.

A despeito da primariedade do réu, afasto o redutor previsto no §4º do artigo 33 da Lei de Drogas. A exorbitante quantidade de drogas apreendidas (207,71 quilogramas de maconha), difere daquela atribuída à figura do traficante ocasional. Destaco que tal quantidade de drogas não é obtida ou confiada ao agente sem que esteja ele ligado à organização criminosa e essa circunstância leva à conclusão de que a causa de diminuição prevista §4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006 é inaplicável.

Ainda nesse tópico, presente a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei de Drogas, razão pela qual elevo a reprimenda em 1/6 (um sexto), atingindo 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Torno a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, ante a ausência de outras causas

modificadoras.

Regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade: Semiaberto, conforme artigo 33, § 2º, alínea "b" do Código Penal.

O pedido do Ministério Público de fixação de regime inicial fechado não deve prosperar visto que já houve declaração, em sede de controle difuso de constitucionalidade, da inconstitucionalidade do § 1º do artigo 2º da Lei nº 8.072/1990, por violação ao princípio da individualização da pena. Neste sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA Habeas corpus. Penal. Tráfico de entorpecentes. Crime praticado durante a vigência da Lei nº 11.464/07. Pena inferior a 8 anos de reclusão. Obrigatoriedade de imposição do regime inicial fechado. Declaração incidental de inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei nº 8.072/90. Ofensa à garantia constitucional da individualização da pena (inciso XLVI do art. 5º da CF/88). Fundamentação necessária (CP, art. 33, § 3º, c/c o art. 59). Possibilidade de fixação, no caso em exame, do regime semiaberto para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade. Ordem concedida. 1. Verifica-se que o delito foi praticado em 10/10/09, já na vigência da Lei nº 11.464/07, a qual instituiu a obrigatoriedade da imposição do regime inicial mente fechado aos crimes hediondos e assemelhados. 2. Se a Constituição Federal menciona que a lei regulará a individualização da pena, é natural que ela exista. Do mesmo modo, os critérios para a fixação do regime prisional inicial devem-se harmonizar com as garantias constitucionais, sendo necessário exigir-se sempre a fundamentação do regime imposto, ainda que se trate de crime hediondo ou equiparado. 3. Na situação em análise, em que o paciente, condenado a cumprir pena de seis (6) anos de reclusão, ostenta circunstâncias subjetivas favoráveis, o regime prisional, à luz do art. 33, § 2º, alínea b, deve ser o semiaberto. 4. Tais circunstâncias não elidem a possibilidade de o magistrado, em eventual apreciação das condições subjetivas desfavoráveis, vir a estabelecer regime prisional mais severo, desde que o faça em razão de elementos concretos e individualizados, aptos a demonstrar a necessidade de maior rigor da medida privativa de liberdade do indivíduo, nos termos do § 3º do art. 33, c/c o art. 59, do Código Penal. 5. Ordem concedida tão somente para remover o óbice constante do § 1º do art. 2º da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07, o qual determina que "[a] pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado". Declaração incidental de inconstitucionalidade, com efeito ex nunc, da obrigatoriedade de fixação do regime fechado para início do cumprimento de pena decorrente da condenação por crime hediondo ou equiparado (STF, Tribunal Pleno, HC 111.840/ES, Rel. Ministro Dias Toffoli, Data do julgamento: 27/06/2012, Data da publicação: 17/12/2013.). Substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito (artigo 44 do Código Penal): Incabível, afinal, o réu foi condenado a pena privativa de liberdade superior a quatro anos (artigo 44, inciso I, do Código Penal).

Suspensão condicional da pena (artigo 77, incisos I, II e III, do Código Penal): Inadmissível, pois o réu foi condenado a pena privativa de liberdade superior a dois anos (artigo 77, caput, do Código Penal).

Valor do dia-multa (artigo 43 da Lei nº 11.343/2006): Ausentes elementos de informação que demonstrem que o réu possui capacidade econômica distinta, atribuo o valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, a cada dia-multa.

DECIDO.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar o réu WELLINGTON FERREIRA por ter praticado fato tipificado no artigo 33, caput, c.c artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06 à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, atribuído a cada dia-multa o valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo federal vigente ao tempo do fato.

Mantenho a prisão preventiva do réu, tendo em vista que os motivos que ensejaram ainda são prevaletentes, reforçados agora pelo édito condenatório.

Noutro giro, não há falar em aplicação da regra prevista no artigo 387, §2º, do

Código de Processo Penal (detração penal), porquanto o benefício não se confunde com progressão de regime; e, ainda, a matéria deve ser analisada pelo Juízo da Execução, o qual possui as informações necessárias para tanto (STJ, HC 443.498/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe15/06/2018).

Condene o réu ao pagamento das custas e despesas processuais. Declaro o perdimento de todos os bens apreendidos com o réu em favor da União, nos termos do artigo 63, inciso I, da Lei nº 11.343/2006.

Proceda-se à destruição da droga apreendida, caso remanescente. Oportunamente, com o trânsito em julgado, oficie-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD) e ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo (TRE-SP), comunicando-os acerca do veredito condenatório.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença registrada eletronicamente.

Pirajuí, 16 de novembro de 2022.